

1500238-41.2021.8.26.0605

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... antecedentes pelo crime de associação para o tráfico (pois o período depurador da reincidência se iniciou em 2013, conforme fl. 145) e estabeleço a pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão, e pagamento de 53 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente, mas confessou o crime. Assim a pena fica inalterada, neutralizando-se as circunstâncias, conforme iterativa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500238-41.2021.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500238-41.2021.8.26.0605

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2205855/2021 - 2º Distrito Policial de Andradina, 19341197 - DEL.SEC.ANDRADINA,

982/2021 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2205855 - 02º D.P. ANDRADINA, 982/21/100 - 02º D.P.

ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS RAFAEL ROSSI

O Ministério Público ofereceu denúncia contra MARCOS RAFAEL ROSSI imputando-lhe a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (Art. 14 "caput" da Lei 10.826/03).

Narra a denúncia que no dia 31 de julho de 2021, por volta das 21h10min, na Rua Homero Rodrigues da Silva, nº 2.694, Centro, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado a fls.07, 09/10, 23, 31 e 37 dos presentes autos, portava uma arma de fogo - um revólver de calibre .38, marca "Taurus", numeração 1902492 -, municiado com cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2021, em decisão de fl.85. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.107/109.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, afastando-se os antecedentes, reconhecimento da confissão e aplicação da pena em regime semiaberto..

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF em fl.01, boletim de ocorrência de fls.02/04, termo de depoimento em fls.05/06, termo de interrogatório em fl.07, autos de exibição e apreensão de fl.08, fotografias em fl.28, laudos periciais de fls.88/92), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada pelos elementos indicados, assim como pela prisão em flagrante e consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral foi no seguinte sentido:

Os policiais militares, responsáveis pela prisão do acusado, ratificaram, sob o crivo do contraditório, a dinâmica dos fatos apresentada na fase investigativa, sem que seus depoimentos fossem neutralizados por reperguntas.

Interrogado, o réu confessou os fatos, dizendo-se "fanático" por armas de fogo.

A perícia técnica constatou estar a arma apta a disparos (fls. 88/92), revestindo-se de potencialidade lesiva necessária para a configuração do crime.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de porte ilegal de arma de fogo é procedente, pois o réu foi flagrado por policiais com um revólver no seu interior, sem qualquer autorização para portar ou mesmo possuir o artefato.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput

e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, observo que o réu é portador de antecedentes criminais.

Deixo de acolher a tese defensiva no sentido de que, depurada a reincidência, apagariam-se os antecedentes criminais.

É certo que reincidência e antecedentes criminais são conceitos distintos, sendo que toda a sistemática da Parte Geral do Código Penal, estabelecida pela Lei 7.209/84, foi estruturada com base em tal dicotomia.

A reincidência traz consequências mais graves para o réu, em diversas etapas dos procedimentos criminais - desde a decretação da prisão preventiva (CPP 310, § 2º), passando-se para a aplicação da pena (arts. 33, 44, 61, I e 77, todos do CP), e também para a execução (arts. 77, 88, 110, todos do CP, além do art. 112 da Lei de

Execução Penal).

Sendo o réu reincidente, veda-se, de plano, a aplicação de regime aberto, de substituição da pena privativa de liberdade, da suspensão condicional da pena, além de outras consequências dispostas nos artigos citados.

Nota-se que a reincidência é algo mais grave, portanto. É por isso que, depurada esta, restam então os antecedentes criminais, os quais poderão, a critério do magistrado, ser valorados nas etapas citadas (fixação de regime prisional, na forma do art. 33, § 3º, substituição da pena, na forma do art. 44, III, suspensão condicional da pena, na forma do art. 77, II, todos do CP).

Quanto à dosimetria da pena, a lei determina ao magistrado, no art. 59, do Código Penal, que ao valorar a pena, atente-se para os antecedentes do acusado. E, como dito, o mesmo Código prevê a reincidência como circunstância agravante mais à frente (art. 61, I), bem como o período depurador (art. 64, I).

Tudo para indicar uma lógica bastante simples: se o legislador previu a reincidência como agravante e trouxe a elas todas as consequências acima listadas, somada ao fato de que após 5 anos da extinção da pena ela não mais remanesceria, e, ao mesmo tempo determinou que o juiz considerasse na primeira fase os antecedentes, só há uma conclusão possível. Para o legislador, o conceito de antecedente criminal é distinto do de reincidência, consubstanciando-se simplesmente na condenação definitiva que não pode (mais) ser valorada como reincidência. Lógica elementar.

Ou isso, ou o próprio legislador teria previsto a aplicação de pena em bis in idem: consideração dos antecedentes na primeira fase e, novamente, na segunda fase, como reincidência, o que seria um absurdo jurídico. Aliás, a súmula 241 do STJ já superou a questão, verbis: "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial".

Ou então o legislador teria colocado no art. 59 do Código Penal uma figura absolutamente inútil e inexistente. Também teria estruturado todos as figuras acima listadas (regime de pena, substituição da pena privativa de liberdade, suspensão da pena, concessão de livramento condicional, consideração da prescrição da pretensão executória) com base na dicotomia reincidência/antecedentes de forma inócua.

Nenhuma de tais opções mostra-se plausível.

Tome-se em conta, ainda, que a reincidência é, como já dito, mais grave que os antecedentes. Natural que, quando apagada a consequência mais gravosa, remanesça uma de menor repercussão jurídica. Para, então, depois, nada restar (conforme se argumentará mais adiante). Há uma progressão na desconsideração dos fatos pretéritos – quanto mais próximo do fato, maior a repercussão; quanto mais o tempo passa, mais se apagam as consequências. Isto parece óbvio.

Dizer que, apagada a reincidência (mais grave), apagam-se os antecedentes (menos grave), seria o mesmo que dizer que, cumprido o lapso temporal da pena em regime fechado, não seria mais necessário cumprir a pena em regime semiaberto ou aberto, já que, cumprida a parte mais grave, as menos graves estariam também cumpridas.

Nota-se que o raciocínio seria o mesmo, e ambos sem qualquer sentido lógico.

Nesse passo, certo que a construção jurisprudencial que vem se formando, no sentido de se apagar totalmente os antecedentes uma vez depurada a reincidência, basicamente despreza toda a estruturação da Parte Geral do Código Penal, estabelecida em 1984, ignorando diversos comandos legais e mais especificamente o art. 59 e revelando-se, assim, entendimento frontalmente contra legem. Em uma palavra: a se acolher tal tese, toda a Parte Geral do Código Penal, além de outros dispositivos, seriam reescritos por via jurisprudencial, sem qualquer embasamento constitucional para tanto.

E nem se diga que se trata de interpretação constitucional para evitar penas de caráter perpétuo. Para tanto, pode-se deixar de valorar os antecedentes, desde que passado prazo razoável após a depuração da reincidência. Este juízo tem adotado o prazo de 5 anos, após a depuração da reincidência, para não mais considerar a condenação pretérita como antecedente criminal, salvo alguma excepcionalidade, como a prática de crime de acentuada gravidade, ou de inúmeros delitos. Aliás, a própria 2ª Turma do STF já aplicou esse entendimento (HC 162.305-SP, HC 126.315-SP e RHC 118.977-MS). Inexplicavelmente, a mesma 2ª Turma decidiu por "avançar" em seu entendimento, figurando mais uma vez o Pretório Excelso como fator de insegurança

jurídica, quando uma de suas missões constitucionais é justamente a de consolidar a integridade do Direito por meio da estabilidade de seus precedentes. Também se construiu a tese de que poderia ser utilizado o prazo prescricional relativo ao delito. Na Câmara dos Deputados foi apresentado pelo Deputado Luiz Flávio Gomes, jurista de renome, o Projeto de Lei 982, de 2019, para inclusão de um parágrafo no art. 59 do Código Penal, com a seguinte redação:

"§ 1º- Para efeito de maus antecedentes, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior aquele na forma do art. 109, não podendo ser inferior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação".

A própria apresentação do projeto, repita-se, por jurista de renome na área do Direito Penal, também serve como demonstração da impropriedade jurídica da construção que pretende apagar completamente o conceito de antecedentes criminais, o qual é previsto em lei.

Tal projeto se baseia em tese construída pelo magistrado Thiago Gomes Baldani De Filippo, a qual foi publicada na revista jurídica Conjur.

Em suma, passado o prazo depurador da reincidência, restam antecedentes criminais, por prazo razoável e que não extrapole a proporcionalidade, deixando de representar pena de caráter perpétuo.

Nesse passo, reconheço os antecedentes pelo crime de associação para o tráfico (pois o período depurador da reincidência se iniciou em 2013, conforme fl. 145) e estabeleço a pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão, e pagamento de 53 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente, mas confessou o crime. Assim a pena fica inalterada, neutralizando-se as circunstâncias, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Sendo assim, a pena fica em 2 anos e 3 meses de reclusão, e pagamento de 53 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista os antecedentes valorados na primeira fase e a reincidência por crime de mesma natureza na segunda fase, com reiteração em período bastante curto, só pode ser o fechado.

Inviável a substituição da pena, em razão dos mesmos parâmetros (CP 44, II e III).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO MARCOS RAFAEL ROSSI, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 2 anos e 3 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 53 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs e determino o perdimento do valor da fiança paga para seu pagamento (CPP 336).

Com o trânsito, i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, ii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado que atuou pelo convênio.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Andradina, 26 de janeiro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)